



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000912070

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 1070175-76.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é embargado BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Rejeitaram os embargos. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.

São Paulo, 10 de novembro de 2021.

SPOLADORE DOMINGUEZ

Relator(a)

Assinatura Eletrônica

Voto nº 15492

Embargos de Declaração nº 1070175-76.2019.8.26.0053/50000

Comarca: São Paulo

Embargante: Município de São Paulo

Embargado: BM Empreendimentos e Participações SPE S/A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vício - Fundamentos do decisorio suficientes à resolução da controvérsia - Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.

Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 1032/1044, deu provimento ao recurso da ora embargada, concedendo a segurança.

Alega o embargante, em resumo e para fins de prequestionamento, que “O v. Acórdão proferido por esta C. Câmara deu provimento ao recurso de apelação do Embargado por entender, em síntese, a existência de conflito entre a disciplina da transferência do direito de construir - TDC pelo Plano Diretor Estratégico – PDE, Lei Municipal nº 16.050/2014, e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS, Lei Municipal nº 16.402/2016, pois o primeiro não teria estabelecido a possibilidade de alteração dos fatores da equação usada para o cálculo do potencial construtivo passível de transferência, nem mesmo para situações excepcionais. Ocorre que, concessa máxima venia, o Município entende que o v. Acórdão padece dos vícios da contradição e da omissão, conforme as razões a seguir. Data máxima venia, ao afirmar que a disciplina do fator de incentivo pelo artigo 24 da LPUOS ofende o PDE, o v. Acórdão deixou de considerar o artigo 133 do PDE, que previu expressamente que tal possibilidade (...). Ou seja, a alteração trazida pelo artigo 24 da LPUOS observou fielmente a regra fixada pelo artigo 133 do PDE. Os fatores de incentivo não foram estabelecidos por tal dispositivo à revelia do PDE, mas com expresse fundamento na autorização nele estabelecida, sem se afastar de suas diretrizes. Importa ressaltar que tal dispositivo foi suscitado pelo Município tanto

nas informações (fls. 844/845) como nas contrarrazões de apelação (fls. 996 e 1001). A Lei Federal n 10.257/01, Estatuto da Cidade, ao regular o instrumento da transferência do direito de construir, assim dispôs: Art. 35 (...).Esse artigo atribui a lei municipal “baseada no Plano Diretor” a possibilidade de estabelecer as condições relativas à aplicação da TDC. Ou seja, o Estatuto da Cidade, lei federal e norma geral da política de desenvolvimento urbano, atribui a outras leis municipais a regulação da aplicação da TDC. No caso em exame, foi precisamente o que se verificou: o PDE regulou em seus artigos 122 a 132 o conteúdo mínimo da TDC exigido pelo artigo 42 do Estatuto da Cidade, estipulando, em seu dispositivo final sobre a matéria (artigo 133), o âmbito de regulação da outra lei municipal específica, autorizando-a expressamente a redefinir os fatores de incentivo, seus critérios de aplicação, bem como a revisão dos perímetros de aplicação do potencial construtivo passível de transferência. Portanto, data maxima venia, mostrou-se contraditório o v. Acórdão ao suscitar o artigo 35 do Estatuto da Cidade e, ao mesmo tempo, afirmar que houve o seu desrespeito pelo artigo 24 da LPUOS que, como dito, simplesmente lhe deu eficácia (...) o artigo 24 da LPUOS nunca foi objeto de qualquer controle de constitucionalidade, de maneira que não poderia ter sua aplicabilidade afastada por órgão fracionário deste E. Tribunal, por força do que dispõe o artigo 97, da Constituição Federal, cujo teor está explicitado pela Súmula Vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal: (...) Portanto, nos termos dos art. 948 e 949 do CPC, que estabelecem um procedimento complexo e a cisão no julgamento, a arguição deveria ter sido submetida à Câmara e, caso acolhida, encaminhada a questão ao C. Órgão Especial, cabendo o julgamento do mérito recursal somente após a rejeição da arguição ou o pronunciamento daquele Órgão.” (fls.1/4)

Eis o breve relato.

À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

O Acórdão embargado, todavia, foi claro ao consignar:

“No Município de São Paulo, o Plano Diretor Estratégico (Lei

Municipal nº 16.050/2014) tratou expressamente da transferência do direito de construir, nos artigos 122 e seguintes, dispondo sobre o modo de calcular o potencial construtivo passível de transferência, inclusive, trazendo a equação a ser utilizada, em seu artigo 125, que assim dispõe:

(...)

Este, portanto, o regramento que deve ser observado, inclusive, pela legislação derivada do Plano Diretor.

Entretanto, a Lei Municipal nº 16.402/2016 (que disciplina o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 Plano Diretor Estratégico - PDE), ao tratar das Zonas Especiais de Preservação Cultural (ZEPEC), regrando a emissão das novas declarações de potencial construtivo passível de transferência, acabou alterando o regramento acima transcrito, no tocante ao “fator de incentivo”, ao dispor, em seu artigo 24, o quanto segue:

(...)

Ora, o Plano Diretor (LM 16.050/2014) não prevê a possibilidade de haver alteração dos fatores daquela equação, usada para o cálculo do potencial construtivo passível de transferência, nem mesmo, para determinadas situações excepcionais. Assim, para tanto, seria necessária a alteração do próprio Plano Diretor.

O conflito do regramento trazido pela LM 16.402/2016 com a regra estipulada pelo artigo 125 do PDE/2014 é flagrante e, no caso, impõe-se a conclusão de que, ao tratar de matéria já regradada pelo Plano Diretor, a nova lei de parcelamento não se amolda à hipótese prevista no Tema de Repercussão Geral nº 348 (“Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”).

Com isso, é forçoso concluir que a Autoridade Impetrada, ao expedir a declaração de potencial construtivo passível de transferência em favor da impetrante, aqui apelante, baseada no regramento trazido pela LM 16.402/2016, cuja ilegalidade é manifesta, como visto acima, feriu direito líquido e certo da impetrante, à expedição do referido documento, nos termos das regras do Plano

Diretor Estratégico (LM 16.050/2014).

Diante do exposto, respeitado o entendimento exposto na sentença recorrida, impõe-se o provimento do recurso, concedendo-se a segurança, para que a Autoridade Impetrada providencie a rerratificação da declaração de potencial construtivo passível de transferência, nos termos do PDE/2014, tal qual buscado pela impetrante."

Verifica-se, assim, que os fundamentos do *decisum*, ainda que não se concorde com eles, foram suficientes à resolução da controvérsia.

Ainda, de acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre

Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. *Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.*

5. *Embargos de declaração rejeitados*”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), j. 08.06.2016) – destaquei.

Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas, questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero reexame da decisão não é admitido, sob pena de desvirtuar-se a própria natureza do instituto.

Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp nº 158.218/RJ, Rel. Min. OLINDO MENEZES – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1ª REGIÃO, 1ª T., j. 20.10.2015).

Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.

SPOLADORE DOMINGUEZ

Relator